15).

A revelação pública daquilo que ocorreu nos bastidores do fórum federal de Curitiba afasta qualquer dúvida que ainda pudesse existir acerca da parcialidade do e**ntão juiz Sérgio Moro, hoje gestor de uma firma de consultoria estrangeira que atua na recuperação judicial de empresas envolvidas na "operação"** que chefiou à margem da lei, evidenciando, quando menos, um olímpico desprezo de sua parte pelos deveres funcionais previstos na Lei Orgânica da Magistratura Nacional e no Código de Ética da categoria.

Esse - por todos os títulos - anômalo proceder do ex magistrado e de integrantes do Ministério Público Federal, encontra-se escancarado nas comunicações entre eles realizadas, especialmente nas datas de 07/12/2015, 21/02/2016, 13/03/2016 16/03/2016, 22/03/2016, 31/08/2016, 09/09/2016 e 13/03/2017, as quais me dispenso de transcrever, dada a sua ampla publicidade.

A instrumentalização do direito em nome de um projeto pessoal e político parece ser um viés presente nas ações penais presididas pelo ex-juiz Sérgio Moro, especialmente as movidas contra o paciente. E a forma como isso se tornou possível, conforme explicitado nos artigos publicados no *O Livro das Suspeições*, organizado por juristas que integram o *Grupo Prerrogativas*, foi a reiterada violação da pedra de toque de qualquer sistema jurídico e de toda democracia digna desse nome: o princípio da imparcialidade dos magistrados. Quanto ao referido princípio e a sua desconsideração pelo então juiz, no âmbito dos processos movidos contra o ex-presidente Lula, o já mencionado Lenio Luiz Streck, em texto que integra o livro, afirma:

> "[...] Nem os notórios processualistas que professam o instrumentalismo negam que a imparcialidade seja um princípio (este, de fato, preenche todos os requisitos exigidos de um princípio). Consequentemente, o artigo 254 deve ser lido a

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

partir da iluminação deontológica do princípio da imparcialidade, previsto, aliás, nas convenções e tratados assinados pelo Brasil de há muito. Por exemplo, o Pacto de San José da Costa Rica - 1969, artigo 8º, e o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que vê o problema da seguinte maneira: exige-se não só a imparcialidade; exige-se a aparência de justiça. A tese é: 'Justice must not only be done; it must also be seen to be done'.

Veja-se que, passado mais de um ano da divulgação dos diálogos entre procuradores da "Lava Jato" e o ex-juiz Sérgio Moro, algumas questões deve(ria)m estar consensuadas:

- Primeiro, que **as conversas configuram relações promíscuas e ilegais entre juiz e membros do Ministério Público**;

- Segundo, **houve a violação de comezinhos princípios éticos e jurídicos acerca do devido processo legal**;

- Terceiro, ficou claro que **a defesa foi feita "de trouxa" pelo juiz e pelo MP, porque combinaram esquema tático sem que ela imaginasse o que estava ocorrendo (a defesa pediu várias vezes a suspeição do juiz);**

- **Quarto, o juiz visivelmente atuou na acusação, violando o princípio acusatório e a imparcialidade; o juiz Moro chegou a sugerir a oitiva de uma testemunha e cobrou mais operações policiais; como diz o jornalista Ranier Bragon, as conversas não dão margem a dúvida: o juiz tomou lado.**

- Quinto, **o conteúdo dos diálogos não foi negado** (falarei na sequência sobre sua (i)licitude).

Por evidente, se isso não é parcialidade, tanto do juiz como do Ministério Público, então teremos que trocar o nome das coisas. Simples assim. Podem Dallagnol e Moro tentar (se) explicar. Mas a rosa não perde seu perfume se a chamarmos de cravo, como na peça Romeu e Julieta, de William Shakespeare.

Fosse na Alemanha, os protagonistas estariam sujeitos ao artigo 339 do Código Penal, aqui traduzido livremente (chama-se de *Rechtsbeugung* - prevaricação): Direcionar juiz, promotor ou qualquer outro funcionário público ou juiz arbitral

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

> o Direito para decidir com parcialidade contra qualquer uma das partes. Pena: detenção de 1 a 5 anos, e multa".[27]

Na mesma obra, ao enfatizar a imparcialidade dos magistrados como um dos pilares centrais do processo penal moderno, Bruno Ribeiro registra a profunda hostilidade que Sérgio Moro nutria contra paciente, manifestada em um programa de televisão. Examine-se:

> "[...] **recentemente, o agora ex-magistrado se referiu à audiência de instrução do processo penal como um 'ringue'. Se o processo penal pode ser um ringue, os lutadores devem ser, naturalmente, a acusação e a defesa, sendo inimaginável que o juiz possa tomar parte de uma delas.** A confissão espontânea do ex-magistrado, certamente, deve retroagir e servir como causa subjacente para questionamento de sua equidistância das partes. Quer como hipótese genérica de quebra de imparcialidade, quer como elemento de convicção acerca da inimizade capital com o acusado, a declaração do ex-magistrado mostra que, no momento da condução do ato instrutório, havia uma animosidade contra o acusado, de onde emerge a hipótese de suspeição".[28]

Consta ainda do mesmo livro a avaliação de que o julgamento do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva insere-se no quadro dos julgamentos de exceção, tal como avaliam Pedro Serrano e Anderson Bonfim. Veja-se:

> "A doutrina do Direito Penal do inimigo, criada na década de 1980 pelo jurista alemão Günther Jakobs, propõe uma distinção entre o Direito Penal do cidadão e um Direito Penal do inimigo. O primeiro formado pela aplicação das normas

27 STRECK, Lenio Luiz. O que fazer quando todos sabemos que sabemos que Moro e o MPF foram parciais? In: *O livro das suspeições*. Rio de Janeiro: Editora Telha, 2020, p 17-18, grifei

28 PEREIRA RIBEIRO, Bruno Salles. Delineamentos sobre a aferição da quebra da imparcialidade do juiz a partir do exame de comportamentos do magistrado responsável pela Operação Lava Jato. In: *O livro das suspeições*, cit., p 35-47, grifei

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

penais vigentes, com respeito às garantias individuais dos cidadãos e exercida nos estritos limites do poder punitivo estatal impostos no âmbito da legalidade, e o segundo, um direito penal especial, voltado aos inimigos, em que há a aplicação de atos lícitos ou ilícitos aos indivíduos que põem em risco a segurança nacional.

Enquanto nos EUA e nos países da Europa continental podemos reconhecer de forma explícita uma jurisprudência do Direito Penal de exceção e medidas de exceção no Direito Penal por meio da criação de leis especiais - ou Direito Penal do inimigo para ficarmos na expressão cunhada por Jakobs - em razão de um Direito especial que é criado para questões de segurança nacional, identificadas com as ameaças terroristas, aqui no Brasil é o próprio direito comum que é utilizado para combater o inimigo (o pobre e o bandido), não pela aplicação de um Direito Penal ou Processual diferenciado para combatê-lo, senão pela utilização de interpretações das normas penais comuns como mecanismos para se instaurar as medidas de exceção contra a própria população que se quer excluir, sob um pretenso legítimo discurso de legalidade.

Nesse sentido, o sistema de Justiça criminal, o qual é composto por vários agentes estatais (Judiciário, Ministério Público, Delegados de Polícia e Polícia, especialmente), com o apoio fundamental da mídia, tornou-se o autor soberano das medidas de exceção. Na referida concepção, a lógica do lícito-ilícito própria do Direito é superada por uma jurisdição de exceção.

A jurisdição de exceção caracteriza-se pela simplificação da decisão a si mesma, sem qualquer mediação real pelo direito. Ademais, caracteriza-se por uma provisoriedade inerente, pois não trata de extinguir o direito, mas de suspendê-lo em situações específicas. Por fim, deparamo-nos com um poder que se apresenta de forma bruta e, por consequência, com sua não autolimitação, nem mesmo por qualquer regra de coerência ou racionalidade. Nesse último aspecto, a decisão judicial de exceção não se influencia nem

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

> produz 'jurisprudência' para situações semelhantes juridicamente. Mudando-se os atores envolvidos ou o fim político, muda-se a decisão, retornando-se ao direito ou produzindo nova exceção".[29]

Por derradeiro, não há como deixar de compartilhar o espanto com a situação revelada nas conversas divulgadas pela mídia, tal como explicitado pelo jornalista Reinaldo Azevedo, em recente artigo. Veja-se:

> "**Se um juiz pode apresentar testemunhas** à acusação; **condescender com truques para fazê-la falar**; **anuir com procedimentos heterodoxos** para imputar ao réu o que não evidenciam os autos nem a denúncia - caso do PowerPoint -; **orientar a desmoralização pública da peça apresentada pela defesa** e até **interferir na escolha,** ainda que por via indireta, **do representante do MPF q**ue vai participar de uma audiência, cabe indagar: **o que é vedado ao juiz**?"[30]

Também aqui vale a pena transcrever um trecho das conclusões a que chegou a juíza federal Fabiana Alves Rodrigues quanto à operação Lava Jato, sobre a qual se debruçou academicamente. Confira-se:

> "[...] o interesse elevado na condução do caso sugere o comprometimento do juiz com o resultado final do processo. Isso esbarra num **princípio caro às democracias: a imparcialidade daquele que ocupa o papel de julgado**r. O Tema é especialmente importante diante da esperada dificuldade na comprovação da parcialidade do juiz, o que talvez explique os diagnósticos preliminares que apontam que os Tribunais são reticentes em reconhecê-la."[31]

---

29 SERRANO, Pedro Estevam Alves Pinto; BONFIM, Anderson Medeiros. Lava-Jato e princípio da imparcialidade. In: *O livro das suspeições*, cit., p 64-74, grifei

30 Havendo lei, condenação de Lula é nula, Folha de São Paulo, 21 de junho de 2019, grifei.

31 RODRIGUES, Fabiana Alves. Op.cit., p. 217, grifei.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

Diante desse cenário, parece-me que não há maior dificuldade em identificar a indisfarçável parcialidade demonstrada por todos os atores institucionais que levaram à condenação do paciente. Comparando-se a miríade de atos processuais heterodoxos objeto deste *writ* com os fatos supervenientes trazidos à lume pelos veículos de comunicação, **não há como deixar de concluir que restou escancarada uma indevida confusão entre as atribuições de julgar e de acusar por parte do então magistrado Sérgio Moro**. E o pior: confusão essa motivada por razões mais do que espúrias. Sim, porque todos os desdobramentos processuais e extraprocessuais - precedentes, concomitantes e posteriores ao término do processo movido contra o paciente - levam ao inexorável desenlace no sentido de que **o ex-juiz extrapolou, a mais não poder, os limites da função jurisdicional da qual estava investido - neutra e imparcial por definição - ao assumir o papel de verdadeiro coordenador dos órgãos de investigação e de acusação, em paralelo às funções de julgador.**

Em outras palavras, f**icou patenteado o abuso de poder com o qual se houve o ex-magistrado**, bem assim o seu completo menosprezo ao sistema processual vigente no País, **por meio da usurpação das atribuições do Ministério Público Federal e mesmo da Polícia Federa**l, além de haver ficado evidente a ocorrência de **ofensa aos princípios do juiz natural e do devido processo lega**l, de permeio a outras irregularidades e ilicitudes.

VI – CONCLUSÃO.

Isso posto, conheço do presente *habeas corpus* e, no mérito, **concedo a ordem, a fim de reconhecer a suspeição do então Juiz Federal Sérgio Moro na condução da Ação Penal 5046512-94.2016.4.04.7000**, que tramitou na 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de Curitiba/PR, **decretando, por consequência, a nulidade integral de todos os atos processuais** levados a cabo no mencionado feito, desde o seu início, sem a possibilidade de qualquer convalidação dos atos instrutórios, todos

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

irremediavelmente tisnados pelo vício insanável da parcialidade.

É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1857-DA08-9F1A-8B5A e senha 2B0D-B0D8-C533-BCBA

09/03/2021 **SEGUNDA TURMA**

HABEAS CORPUS 164.493 PARANÁ

APARTE

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) - Ministro Lewandowski, eu queria aproveitar esta sua passagem falando de Ferrajoli para lembrar que ele é um dos subscritores daquele manifesto, a que me referi a propósito do julgamento verificado em Curitiba, chamando a atenção do Supremo Tribunal Federal para a gravidade dos eventos e dos fatos que foram revelados. Assim como a *Ms.* Ackerman**,** também Ferrajoli é um dos grandes nomes que subscreve aquele documento ao qual fiz referência.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Vossa Excelência, como eu, e tantos outros do Supremo Tribunal Federal que viajam amiúde para o exterior para palestras, para conferências, para troca de ideias com outros professores e outros acadêmicos, eu tenho dito a Vossa Excelência que, toda vez que vou para o exterior, trago de volta a perplexidade da opinião pública internacional, sobretudo da comunidade jurídica acadêmica internacional, sobre este processo que envolve o ex-presidente, quer dizer, desperta a maior credulidade.

E eu sempre tive enorme dificuldade em me justificar, como integrantes do Judiciário, como integrante da Suprema Corte, sobre o que aconteceu neste processo que é objeto do *habeas corpus* que estamos agora examinando.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código DC56-248A-45A7-C1A3 e senha DFF0-79A8-CE15-A2BD

09/03/2021 **SEGUNDA TURMA**

HABEAS CORPUS 164.493 PARANÁ

APARTE

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) - Ministro Lewandowski, Vossa Excelência me permite só uma consideração? Desculpe-me!

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Claro, por favor!

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) - Só para ver como essa questão da competência era manipulada, um dos diálogos - certamente a eles Vossa Excelência teve acesso -sobre essa questão da competência - agora muito bem-decidida pelo Ministro Fachin. Veja, Vossa Excelência, o seguinte diálogo que ocorre:

"- Falei que vamos tocar por aqui. Mesmo que depois nos tirem, pois não é Petrobras.

- Athayde quer roubar o caso.

- Mas tem conexão? Pessoal da zelotes tá com medo de a gente roubar."

Veja o tipo de conversa!

"- Se sair das quebras de Curitiba, é conexo com a Lava Jato.

- Se o avião usou combustível da Petrobras é nosso!"

Vejam, Vossas Excelências, Ministro Lewandowski, Ministra Cármen, Ministro Fachin, Ministro Nunes Marques, veja, caro Juliano, vejam aonde tínhamos chegado, aonde tínhamos chegado!

Difícil imaginar onde mais descer na escala das degradações.

"- Não Tata?

- Creio que a zelotes tem sua razão de reclamar, mas...

- Eu, Deltan, não concordo. A competência é límpida e clara.

- Combustível da BR Dist é nosso e já tem grupo prevento..."

Brincava-se com essa questão da competência. Aquela ideia que o Ministro Toffoli ressaltou naquele precedente de um tipo de foro universal, e que suscita um problema.

Tenho por hábito não chorar o passado e tentar propor soluções.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E265-51E1-76D8-BC4E e senha C30D-8295-C3FF-2AD2

Creio que estamos diante de um grande desafio. Essas varas de lavagens - e já tinha falado para um dos seus conceptores, Ministro Gilson Dipp - já deram problemas imensos e vão dar mais, vão dar mais, com as delações!

Nos casos das delações, em um dos diálogos, faz-se menção a alguém que fez delação, mas que estava com Alzheimer. Sabe, não precisa dizer mais nada. Ou aquele episódio da delegada Marena, que veio para a DRSI, aquela que prendeu, arbitrariamente, o Reitor da Universidade de Santa Catarina, imputando a ele um desvio de oitenta milhões, quando o projeto era de oitenta milhões. Essa senhora aparece agora fazendo um depoimento falso e os Procuradores dizem: "Oh, há uma falsidade, mas temos que proteger a Marena."

Vejam os Senhores, é, de fato, altamente constrangedor: "Rubito, combustível da BR-Distribuidora. É nosso também, Grupo Prevento. Creio que a PF merece uma visita na segunda. Temos uma reunião marcada ou passa, e eu irei junto para falar com..."

Isso está nesses diálogos. Isso é chocante, isso é vergonhoso, isso é constrangedor! Em boa hora, o Ministro Edson Fachin tomou essa providência.

É interessante, Ministro Lewandowski, que esse ponto que Vossa Excelência está focando e que está nos embargos de declaração, sobre a competência, mereceu da pena talentosa de Reinaldo Azevedo - veja, sem formação jurídica; até já disse a ele que vou propor, se tiver ainda alguma influência, que o IDP lhe dê título de Doutor *Honoris Causa* - uma análise dessa sentença. Ele perscrutou essa questão da competência e explorou esse aspecto, que Vossa Excelência agora está colocando sobre a questão da competência:

Onde estava o *link*, o elo entre a Petrobras e esse triplex? Alguma coisa com uma empresa que fazia obras Brasil afora e mundo afora. Onde encontraram esse *link*? Talvez no combustível que servia os carros da BR-Distribuidora, quer dizer, talvez o carro talvez dirigido pelo...

Veja, isso é muito sério!

Em boa hora, quero deixar também meus efusivos cumprimentos ao Ministro Edson Fachin, por essa decisão, porque, de fato, põe cobro a um

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E265-51E1-76D8-BC4E e senha C30D-8295-C3FF-2AD2

festival de abusos.

Era algo elástico, flexível, cabia tudo na Vara, como também na 7ª Vara do Rio de Janeiro. Temos tido casos em que têm de ser retirados, porque também ela se tornou algo espiritual. Qualquer coisa que tenha a ver com corrupção na esfera estadual vai para a Justiça Federal, para 7ª Vara, que, como disse, está extremamente mal falada.

Não sei se já ouviram falar, Senhores Ministros, de um personagem que gravita por aí e que fez uma reclamação no STJ chamado Nitalmar, advogado que liderava as delações até dado momento e depois se tornou uma figura espúria. Fizeram uma investigação em relação a ele, e ele veio reclamar no STJ.

Virou um antro, um grande problema. Por isso, tenho dito aos meus amigos do STJ, do Conselho da Justiça Federal: "Façam alguma coisa antes que a Justiça Federal se comprometa de maneira indelével, de maneira irreparável!" Isso é muito sério!

Mas, desculpe-me pela interrupção. Espero não ter quebrado a linha de seu raciocínio.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Não! Vossa Excelência trouxe achegas extremamente importantes, complementares.

Também aproveito para parabenizar o Ministro Fachin por ter levantado essa questão importantíssima, que, desde sempre, estava implícita nesses e em outros autos.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E265-51E1-76D8-BC4E e senha C30D-8295-C3FF-2AD2

09/03/2021 **SEGUNDA TURMA**

HABEAS CORPUS 164.493 PARANÁ

ADITAMENTO AO VOTO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, aderindo, à proposta de Vossa Excelência, de que as custas sejam suportadas pelo Juiz ora considerado suspeito e parcial.

Na volta do julgamento, posso, eventualmente, tecer outras considerações. Mas, por hora, é como voto, Senhor Presidente.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 733D-C38D-17C0-60F6 e senha 4697-F792-9681-8E95

09/03/2021 **SEGUNDA TURMA**

HABEAS CORPUS 164.493 PARANÁ

RELATOR	**: MIN. EDSON FACHIN**
REDATOR DO ACÓRDÃO	**: MIN. GILMAR MENDES**
PACTE.(S)	: LUIZ INACIO LULA DA SILVA
IMPTE.(S)	: CRISTIANO ZANIN MARTINS (32190/DF, 153599/RJ, 172730/SP) E OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES)	: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

OBSERVAÇÃO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Senhor Presidente, eminentes Pares, como todos os votos não foram proferidos e eu havia aquiescido com a ideia do eminente Ministro Lewandowski, manifestar-me-ei após o voto do eminente Ministro Nunes Marques.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3BA5-BA23-343E-B487 e senha A760-7A38-DDDE-3B16

SEGUNDA TURMA

EXTRATO DE ATA

HABEAS CORPUS 164.493
PROCED. : PARANÁ
RELATOR : MIN. EDSON FACHIN
REDATOR DO ACÓRDÃO : MIN. GILMAR MENDES
PACTE.(S) : LUIZ INACIO LULA DA SILVA
IMPTE.(S) : CRISTIANO ZANIN MARTINS (32190/DF, 153599/RJ, 172730/SP) E OUTRO(A/S)
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Decisão: A Turma, por maioria, deliberou a continuidade do julgamento, não obstante o pedido de adiamento por parte da defesa, e deliberou também que a matéria não fosse afetada ao Plenário, vencidos os Ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Prosseguindo no julgamento, e após o voto do Ministro Edson Fachin (Relator) que não conhecia do *Habeas Corpus* no que foi acompanhado pela Ministra Cármen Lúcia, pediu vista o Ministro Gilmar Mendes. Aguardam os demais. Falaram: o Dr. Cristiano Zanin Martins pelo Paciente e a Dra. Cláudia Sampaio Marques, Subprocuradora-Geral da República, pelo Ministério Público Federal. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. **2ª Turma**, 4.12.2018.

Decisão: A Turma, por maioria, deliberou adiar o julgamento do feito, vencido o Ministro Ricardo Lewandowski, e, também por votação majoritária, indeferiu a concessão de liminar, proposta pelo Ministro Gilmar Mendes, no que foi seguido pelo Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência da Ministra Cármen Lúcia. **2ª Turma**, 25.6.2019.

Decisão: A Turma, por maioria, rejeitou a questão de ordem suscitada pelo Ministro Edson Fachin, decidindo que a decisão proferida pelo relator nos autos dos Embargos de Declaração no Habeas Corpus 193.726 em 08.03.2021 não acarretou a prejudicialidade do Habeas Corpus 164.493, vencido, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin. Prosseguindo no julgamento, e após o voto do Ministro Gilmar Mendes, que concedia a ordem em *habeas corpus*, determinando a anulação de todos os atos decisórios praticados pelo magistrado no âmbito da Ação Penal n. 5046512-94.2016.4.04.7000/PR incluindo os atos praticados na fase pré-processual e, com fundamento no art. 101 do Código de Processo Penal, determinava ainda que o juiz excepto Sérgio Fernando Moro fosse condenado ao pagamento das custas processuais da ação penal, na forma da lei, no que foi acompanhado pelo Ministro Ricardo Lewandowski, pediu vista o Ministro Nunes Marques. Presente à sessão pelo Paciente o Dr. Cristiano Zanin Martins. Presidência do

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A32F-DBBD-2280-D72C e senha F0D5-D89C-7594-E3BC

Ministro Gilmar Mendes. 2ª Turma, 9.3.2021.

Presidência do Senhor Ministro Gilmar Mendes. Presentes à sessão os Senhores Ministros Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Edson Fachin e Nunes Marques.

Subprocurador-Geral da República, Dr. Juliano Baiocchi.

Maria Clara Viotti Beck
Secretária

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código A32F-DBBD-2280-D72C e senha F0D5-D89C-7594-E3BC

23/03/2021 **SEGUNDA TURMA**

HABEAS CORPUS 164.493 PARANÁ

V O T O V I S T A

O SENHOR MINISTRO NUNES MARQUES: Trata-se de *habeas corpus* impetrado em favor de **Luiz Inácio Lula da Silva** contra decisão proferida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao **Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no *Habeas Corpus* 398.570/PR**, cujo acórdão tem a seguinte ementa:

> "PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM *HABEAS CORPUS*. RECURSO INTERPOSTO CONTRA V. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO *WRIT* IMPETRADO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA E SUSPEIÇÃO DO JUÍZO PRIMEVO. INCOMPETÊNCIA NÃO VISLUMBRADA DE PLANO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE. SUSPEIÇÃO. QUESTÃO JÁ ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM EM INCIDENTE PRÓPRIO. FATOS NOVOS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO ANTERIOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
>
> **I –** Faz-se excepcional a arguição de incompetência em sede de *habeas corpus*, devendo ser manifesta a ilegalidade e demonstrada de plano, através de prova pré-constituída e desde que não seja necessária a incursão no conjunto fático probatório.
>
> **II –** Não se admite a presente via recursal quando a matéria ainda não foi apreciada definitivamente pelo órgão judiciário apontado como coator, sob pena de supressão de instância.
>
> **III –** *In casu*, não se conheceu do *writ*, em razão da impossibilidade de se vislumbrar flagrante ilegalidade referente a incompetência do Juízo, seja pela necessidade de aprofundamento em matéria de prova ou mesmo diante da complexidade e dimensão da própria matéria controvertida.
>
> **IV – A ausência de imparcialidade do magistrado já**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1EC0-CAB7-C800-C0AA e senha 918B-1E01-7813-7923

> **foi examinada nos incidentes próprios, não sendo cabida a reabertura de matéria já decidida com base na mera indicação de 'fatos novos'.**
>
> Agravo Regimental não provido." (grifei)

Sustentam os impetrantes, em síntese, a suspeição do juiz prolator da sentença condenatória do paciente, na Ação Penal nº 5046512--94.2016.4.01.7000, originária da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná, apresentando como provas cópias de decisões proferidas nos autos e de reportagens de jornais.

O eminente Ministro EDSON FACHIN, Relator, **não conheceu** do *habeas corpus*, sendo acompanhado pela eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA. Pediu vista o eminente Ministro GILMAR MENDES.

Na sessão de 09/03/2021, o eminente Ministro GILMAR MENDES, divergindo do Relator, concedeu a ordem de *habeas corpus*, "*determinando a anulação de todos os atos decisórios, praticados pelo magistrado no âmbito da AÇÃO PENAL n. 5046512-94.2016.4.04.7000/PR (Triplex do Guarujá), incluindo os atos praticados na fase pré-processual*".

Sua Excelência votou ainda pela revogação, de forma definitiva, da prisão do paciente, afirmando a ilegalidade daquele ato e ressaltando "*que a suspeição do julgador se fundamenta em fatos concretos e específicos contra LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, em razão de interesses políticos próprios do ex-juiz SERGIO MORO*". O referido voto destacou, ademais, que não há impedimento para eventual novo processo contra o paciente, desde que sob a presidência de juiz imparcial.

Finalmente, no mesmo voto, o eminente Ministro GILMAR MENDES, com fulcro no art. 101 do Código de Processo Penal, condenou o ex-Juiz Federal SERGIO FERNANDO MORO ao pagamento das custas processuais da ação penal.

O eminente Ministro RICARDO LEWANDOWSKI acompanhou a

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1EC0-CAB7-C800-C0AA e senha 918B-1E01-7813-7923

divergência instaurada pelo eminente Ministro GILMAR MENDES.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a controvérsia e agora os trago para prolação do **meu voto.**

Senhores Ministros, vários são os questionamentos que a presente ação provoca.

I – Sustentam os impetrantes que este *habeas corpus* deve ser conhecido, porque há prova pré-constituída das alegações; e que os fatos novos trazidos à consideração do Tribunal autorizariam a superação de uma eventual preclusão.

Há várias questões fáticas controvertidas.

Indago, desde logo: todas podem ser aferidas documentalmente, **sem qualquer dúvida ou questionamento**?

A mera extensão ou a complexidade dos fatos não desautorizam que sejam eles alegados na via do *habeas corpus*, mas sim a necessidade de serem aferidas a sua **liquidez e certeza**, ou seja, se os **documentos apresentados** têm aptidão para comprovar aqueles fatos de maneira inquestionável. Daí a necessidade de examinar-se e verificar-se a **volumosa documentação apresentada**.

II – Mais: Os **fatos arrolados** como indicativos de suspeição do juiz de primeiro grau estão cabalmente demonstrados pelos **documentos juntados pela defesa**?

Se estão demonstrados, do exame de seu conjunto, **é possível extrair-se a conclusão jurídica alegada pela defesa** (a suspeição daquele que era então juiz do processo)? Ou seriam necessárias **mais provas de outros fatos** (**não mencionados pela parte impetrante, mas com relevo para o caso**)?

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1EC0-CAB7-C800-C0AA e senha 918B-1E01-7813-7923

Há também o problema de se considerar **válida a utilização de provas decorrentes ou objeto da prática de um ilícito ou de um delito**. É possível fazê-lo? Para acusar, com certeza, não. E para se defender? Em certas circunstâncias, sim. **Nesse caso**, **é admissível o uso de tal tipo de prova**?

III – **Se for admissível o uso dessa prova** (**ilícita**), surge novamente o problema de cabimento do *writ*. Pode-se afirmar, sem dúvida, serem essas provas hígidas, isto é, **isentas de qualquer contrafação**, **sem a realização de exame pericial**, mas se baseando unicamente em exame técnico levado a cabo pela própria parte interessada?

Continuo nas indagações: **sendo as provas admissíveis**, elas devem vir ao Poder Judiciário na via estreita do *habeas corpus* **diretamente no Supremo Tribunal Federal**? Ou deveriam ser introduzidas no bojo do processo penal, no estágio em que se encontre, perante as instâncias ordinárias, ou mesmo em revisão criminal (caso já haja trânsito em julgado do processo criminal)?

Refiro-me especificamente a esse ponto, porque **a introdução da prova neste grau de jurisdição, em sede de *habeas corpus*, impede o estabelecimento de contraditório com a parte adversa (acusação) e até mesmo com o juiz arguido de suspeito, que não pode sequer se defender das acusações** — muito menos de forma ampla, com a realização de perícia sobre a prova documental posteriormente juntada.

Adicione-se a isso o fato de que a parte adversa (no caso, a acusação) também não tem como ilidir as alegações da impetração, na via estreita do *habeas corpus*, que **não admite dilação probatória** — e o MPF atua aqui apenas como *custos legis*.

Essas são questões que demandam profunda reflexão do

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1EC0-CAB7-C800-C0AA e senha 918B-1E01-7813-7923

Colegiado.

Como fundamentos para a suspeição do ex-juiz Sergio Moro, invocam-se: (i) a acusação de parcialidade em determinadas condutas do ex-magistrado, quando presidia o processo do qual foi extraído o presente HC; e (ii) as provas juntadas de forma superveniente relativas à interceptação de dados telemáticos de autoridades, obtidas e divulgadas por um *site* da internet denominado **The Intercept Brasil**.

O eminente Ministro EDSON FACHIN não conheceu do *habeas corpus,* ao entendimento de que a presente impetração limita-se à suspeição daquele que, então, era o magistrado titular da 13ª Vara Federal de Curitiba.

E assim consignou: que "*o tema não concerne a qualquer incidente de execução penal*"; que "*os argumentos acerca da suposta ausência de imparcialidade do magistrado já foram examinados em três exceções de suspeição anteriormente opostas, não sendo cabida a reabertura da matéria já decidida com base na mera indicação de fatos novos*".

As **Exceções de Suspeição ns. 5032506-82.2016.4.04.7000**, **5032521-51.2016.4.04.7000** e **5032531-95.2016.4.04.7000**, julgadas de forma conjunta pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em sessão realizada no dia 26/10/2016, receberam a seguinte ementa:

> "PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. 'OPERAÇÃO LAVA-JATO'. ATOS DO PROCESSO. DEVER DE FUNDAMENTAR. EXCESSO NÃO CONFIGURADO. ARTIGOS PUBLICADOS. IMPARCIALIDADE NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO OU INTERESSE NA CAUSA. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPROCEDÊNCIA DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO CRIMINAL.
>
> 1. Não gera impedimento do magistrado, tampouco

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1EC0-CAB7-C800-C0AA e senha 918B-1E01-7813-7923

implica em antecipação do juízo de mérito, a externalização das razões de decidir a respeito de diligências, prisões e recebimento da denúncia, comuns à atividade jurisdicional e exigidas pelo dever de fundamentar estampado na Constituição Federal.

2. A determinação de diligências na fase investigativa, como quebras de sigilo telemáticos e prisões cautelares não implica antecipação de mérito, mas sim mero impulso processual relacionado ao poder instrutório.

3. A ampla cobertura jornalística à investigação denominada de 'Operação Lava-Jato', bem como a manifestação da opinião pública, favoráveis ou contrárias, para as quais o magistrado não tenha contribuído, ou, ainda, a indicação do nome do excepto em pesquisas eleitorais para as quais não tenha anuído, não acarretam a quebra da imparcialidade do magistrado.

4. Eventuais manifestações do magistrado em textos jurídicos ou palestras de natureza acadêmica, informativa ou cerimonial a respeito de crimes de corrupção, não conduz à sua suspeição para julgar os processos relacionados à 'Operação Lava-Jato'.

5. Considerações do magistrado em texto jurídico publicado em revista especializada a respeito da Operação Mãos Limpas (Itália) têm natureza meramente acadêmica, descritiva e informativa e não conduzem à sua suspeição para julgar os processos relacionados à 'Operação Lava-Jato', deflagrada, inclusive, muitos anos depois. De igual modo e por terem o mesmo caráter acadêmico, não autoriza que se levante a suspeição do magistrado ou mesmo o seu desrespeito às Cortes Recursais.

6. O art. 256 do Código de Processo Penal prevê que a suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida, quando a parte injuriar o juiz ou, de propósito, der motivo para criá-la, evitando assim ações deliberadas com o objetivo de afastar o magistrado da causa. Hipótese em que a representação do excipiente em face do excepto perante a Procuradoria-Geral da República por crime de abuso não será suspeição.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1EC0-CAB7-C800-C0AA e senha 918B-1E01-7813-7923

> 7. A limitação de distribuição de processos ao juízo excepto diz respeito à administração da justiça da competência do Tribunal Regional da 4ª Região e não guarda correspondência com as causas de suspeição previstas no CPP ou implica em quebra de isenção do excepto.
>
> 8. Exceção de suspeição a que se nega provimento."

Os julgados do TRF da 4ª Região deram ensejo aos **AREsp ns. 1.097.624**, **1.102.139** e **1.105.620**, no Superior Tribunal de Justiça, e aos **ARE ns. 1.100.658**, **1.097.078 e 1.096.639**, no Supremo Tribunal Federal, **todos desprovidos e com trânsito em julgado, nesta Corte, em 25/04/2018.**

Nesse sentido, concluiu o eminente Ministro EDSON FACHIN que: "*a pretensão defensiva, ao menos em relação à parcela dos fatos elencados como indicativos da suspeição ora alegada, **foi exercida em estrita observância à garantia constitucional ao devido processo legal**, **pois impulsionada pela via correta**, **a saber**, **a exceção de suspeição**, **prevista no art. 95**, **I**, **do Código de Processo Penal***" (grifei).

E, mais: que "*os respectivos provimentos jurisdicionais **foram objeto de impugnação por intermédio dos recursos cabíveis no ordenamento jurídico pátrio**, quais sejam, os recursos especial e extraordinário, bem como dos subsequentes agravos visando à reforma das decisões de inadmissibilidade, **esgotando-se**, assim, **todas as instâncias ordinárias e revisionais** da estrutura do Poder Judiciário desenhada pelo legislador constituinte originário*", estando alcançados pelo trânsito em julgado, tratando-se, portanto, "*de **questões estabilizadas no contexto da relação processual** desenvolvida perante as instâncias de origem que, **à luz da regra prevista no art. 111 do Código de Processo Penal**, não foi suspensa, o que impede o conhecimento da impetração no tocante aos fatos supra delimitados, em homenagem à **segurança jurídica preconizada no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal***" (grifei).

É certo que, como bem salientou o eminente Ministro Relator,

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1EC0-CAB7-C800-C0AA e senha 918B-1E01-7813-7923

esta Corte, por ocasião do julgamento do RHC 82.045/SP, Rel. Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE (DJ de 25/10/2002), entendeu que "*a coisa julgada estabelecida em processo condenatório não é empecilho, por si só, à concessão de 'habeas corpus' por órgão jurisdicional de gradação superior, de modo a desconstituir a decisão coberta pela preclusão máxima*".

Tal entendimento, contudo, **não é aplicável à hipótese dos autos**, uma vez que, como ressaltado pelo Ministro EDSON FACHIN, "*a irresignação defensiva, como visto, foi* ***analisada por este Supremo Tribunal Federal*** *no julgamento dos ARE 1.100.658, 1.097.078 e 1.096.639, e* ***refutada em função dos limites cognitivos da competência recursal*** *disciplinada na Constituição Federal, com destaque para a* ***inviabilidade de nova incursão no conjunto fático-probatório à reforma das conclusões exaradas pelas instâncias de origem***".

Bem a propósito, eis a ementa do acórdão do **HC 127.461-AgR/SP**, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016:

> "*HABEAS CORPUS*. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL. VEDAÇÃO. ART. 131, § 2º, DO RISTF. IMPEDIMENTO DE MAGISTRADO. MATÉRIA QUE PRESSUPÕE EXAME APROFUNDADO DE ELEMENTOS FÁTICOS. AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE O TEMA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
>
> ….....
>
> 2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça **está de acordo com a jurisprudência desta Corte, fixada no sentido de que, rejeitada a exceção de suspeição pela instância ordinária, não é possível apontar qualquer ilegalidade ou arbitrariedade sanável na via do *habeas corpus*, por pressupor exame aprofundado de elementos fáticos da causa**.
>
> 3. Ademais, a alegada suspeição ou impedimento do Magistrado esbarra na inviabilidade de supressão de instância, uma vez que inexiste decisão definitiva no STJ sobre a questão,

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1EC0-CAB7-C800-C0AA e senha 918B-1E01-7813-7923

estando pendente de julgamento recurso especial interposto nos autos da exceção de suspeição.

4. Pedido de sustentação oral indeferido. Agravo regimental improvido." (grifei)

E, no mesmo sentido, mais:

"Recurso ordinário em *habeas corpus*. Processual Penal. Suspeição. **Sucessivas decisões judiciais desfavoráveis ao recorrente**. **Parcialidade do magistrado**. **Reconhecimento em sede de *habeas corpus***. **Inadmissibilidade**. **Precedentes**. Questão deveras controvertida. Decisões proferidas no exercício independente da atividade jurisdicional. **Escolha justificada de uma interpretação possível**. Faculdade de sua impugnação por recurso ou ação autônoma. **Impossibilidade de se confundir quebra de imparcialidade com decisões contrárias aos interesses do réu**. Precedente. **Perquirição do suposto ânimo persecutório do magistrado. Necessidade de revolvimento de material fático-probatório. Via inadequada**. Recurso não provido.

1. A pretensão do recorrente de glosar atos judiciais que contrariaram seus interesses, para deles se extrair a suspeição do magistrado, **colide com pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o *habeas corpus* não constitui a via idônea para essa discussão**. Precedentes.

2. A via própria é a exceção de suspeição, na qual se admite a produção de provas, inclusive testemunhal (**art. 98, CPP**). Trata-se, portanto, **de um incidente de ampla cognição probatória**.

3. Na espécie, o recorrente opôs exceção de suspeição do magistrado de primeiro grau, que não a reconheceu, vindo o Tribunal Regional Federal da 4ª Região a rejeitá-la.

4. A alegada quebra do dever de imparcialidade, por razões não declaradas pelo magistrado e supostamente diversas das subjacentes à real motivação de suas decisões, **é deveras controvertida, uma vez que se trata de decisões**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1EC0-CAB7-C800-C0AA e senha 918B-1E01-7813-7923

motivadas, proferidas no exercício independente da atividade jurisdicional e impugnáveis por recurso ou ação autônoma.

5. **Decisão judicial em que se justifique a escolha de uma interpretação possível não é apta, por si só, a gerar a suspeição de seu prolator**, e sua revisão pelas instâncias superiores **não significa que o magistrado tenha atuado de forma direcionada a prejudicar o recorrente**.

6. Com efeito, "***não se pode considerar um Magistrado suspeito por decidir de acordo com tese jurídica que considera correta, pois se estaria atingindo o exercício da atividade jurisdicional***" (RHC nº 127.256/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro GILMAR MENDES, DJe de 10/3/16).

7. Outrossim, **a quebra do dever de imparcialidade não se confunde com decisão contrária aos interesses do réu**.

8. Para se concluir de forma diversa, seria **mister o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de se perquirir o suposto ânimo persecutório do magistrado em desfavor do recorrente, o que é inviável na estreita via do *habeas corpus***. Precedentes.

9. Recurso não provido."

(**RHC 131.544/PR**, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016 – grifei)

"AGRAVO REGIMENTAL EM *HABEAS CORPUS*. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA.

1. O acórdão impugnado assentou que o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de elementos aptos a comprovar a alegada imparcialidade do magistrado e que o afastamento dessa conclusão encontra óbice na Súmula 7 do STJ, ante a impossibilidade de reexame de fatos e provas em recurso especial.

2. Arguida a suspeição na via processual específica, tendo sido rejeitada pela instância ordinária, mediante **exame suficiente da decisão supostamente ensejadora da quebra de dever de parcialidade do magistrado, não é possível apontar**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1EC0-CAB7-C800-C0AA e senha 918B-1E01-7813-7923